

1500581-09.2022.8.26.0603
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: DANILO BRAIT
Comarca: Araçatuba
Foro: Foro de Araçatuba
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 18/10/2022
...

Cabe ponderar, ainda, que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse ou guarda do tóxico pelo agente para entrega a terceiro sendo, portanto, desnecessário que seja ele flagrado vendendo a droga. A propósito, sobre o tema este Tribunal já decidiu que: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araçatuba
Foro de Araçatuba
3ª Vara Criminal
Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

1500581-09.2022.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500581-09.2022.8.26.0603
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Boletim nº BB0174-1/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO - 2ª ENTORPECENTES - DEIC -
DEINTER 10
Autor:
Justiça Pública
Réu:
KAIO AUGUSTO DA SILVA SOUSA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANILO BRAIT

Vistos.

KAIO AUGUSTO DA SILVA SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 porque, no dia 12 de abril de 2022, por volta das 19h30, na rua João dos Santos Lima, n.º 698, bairro Águas Claras, nesta cidade, trazia consigo e tinha em depósito droga sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante em 12/04/2022. Pela r. decisão de fls. 34/37 foi concedida ao acusado a liberdade provisória, com cumprimento do alvará de soltura em 13/04/2022 (fls. 50/51).

O réu foi notificado à fl. 84 e apresentou defesa prévia às fls. 89/94. Não estando presente quaisquer das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, a denúncia foi recebida em 24/08/2022 (fls. 99/100).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo, ao final, interrogado o acusado (fls. 114/120).

Em alegações finais (fls. 114/116), o representante do Ministério Público pugnou, em síntese, pela procedência da ação, com a condenação do réu nos moldes da denúncia, vez que comprovadas a materialidade e autoria do crime, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Em alegações finais (fls. 124/129), a defesa do réu requereu inicialmente o reconhecimento de nulidade, em razão da invasão de domicílio pelos policiais. No mérito, requereu a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, com aplicação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, requer seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

De início, rejeito a preliminar de nulidade processual, não havendo que se falar em violação de domicílio praticada pelos policiais militares no caso vertente.

Segundo consta dos autos, os policiais avistaram o réu durante patrulhamento de rotina, o qual apresentou nervosismo e dispensou uma sacola plástica, contendo treze pinos de cocaína. Em revista pessoal, foi encontrada com ele também a quantia de R\$ 100,00. Indagado, o acusado teria confessado que havia mais drogas em sua residência, que era próxima do local da abordagem. Então, dirigiram-se ao imóvel, sendo a busca autorizada e acompanhada pelo detido, que inclusive, indicou aos policiais que havia entorpecentes em seu guarda-roupas, onde de fato foram encontradas porções de cocaína e maconha.

Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603616, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015).

Neste contexto, "o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (STJ, REsp 1558004 RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/08/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2017).

Ressalto que o delito de tráfico de drogas possui como característica a permanência, de modo que é facultado ao agente policial o ingresso na residência, independentemente de ordem judicial ou acompanhamento do acusado, a fim de cessar a prática delituosa (artigo 303 do Código de Processo Penal). Com efeito, o próprio dispositivo constitucional que consagra a garantia da inviolabilidade de domicílio excepciona os casos de flagrante delito (artigo 5º, inciso XI, da Constituição

Federal). Assim, o agente que tem em depósito substância entorpecente, para fins de entrega a consumo de terceiros, está em situação de flagrância, a ponto de, por exceção constitucional, autorizar que a autoridade policial ingresse na residência mesmo sem mandado ou autorização do morador.

No caso dos autos, consta que o réu dispensou uma sacola plástica contendo treze pinos de cocaína, indicando aos policiais que havia mais drogas em sua casa, que distava aproximadamente 80 metros do local da abordagem.

Portanto, evidenciado o flagrante pelo crime de tráfico de drogas, o ingresso no imóvel se mostrava lícito e permitido, conclusão que, não só a Constituição acata, como a lógica recomenda: houvesse garantia absoluta, que modernamente não se concebe, o domicílio, equivocadamente alçado à fortaleza impenetrável, serviria não como proteção à intimidade e vida privada, mas à prática de graves ilícitos.

Com efeito, ficaram demonstrados nos autos os indícios razoáveis da existência de crime permanente, aptos a afastar a necessidade de autorização para ingresso na residência. Tais fatos inegavelmente legitimam o ingresso no domicílio, vez que a diligência policial se baseou em elementos concretos que indicavam a ocorrência de tráfico dentro do imóvel.

Portanto, o pedido defensivo de nulidade das provas obtidas por meio ilícito não comporta acolhimento.

No mérito, o pedido inicial é procedente.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/07), auto de exibição e apreensão (fl. 09), laudos de constatação prévia de entorpecentes (fls. 27/28), laudos de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 61/66), pelo relatório policial (fls. 67/68), bem como pela prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria também é certa.

O policial militar Josias Guerrero Junior, ouvido em juízo (fl. 118), em consonância com o depoimento prestado na fase inquisitiva (fl. 02), relatou que estavam realizando patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando avistaram o réu, que estava andando no meio da via sozinho. Ao perceber a aproximação da viatura, o réu se dirigiu para a calçada e dispensou um saco plástico no chão. Realizaram a abordagem e, em busca pessoal, foi encontrada a quantia de R\$ 100,00. No saco plástico dispensado pelo réu foram encontrados treze microtubos contendo cocaína. Indagado, o réu negou de início a prática ilícita, mas depois acabou confessando que estava realizando a venda do entorpecente encontrado. Também informou que morava numa casa próxima dali e que havia no seu guarda-roupas mais drogas. Dirigiram-se ao local, sendo a busca autorizada e acompanhada pelo réu. Lá foram encontrados, no guarda-roupas, mais cinquenta pinos contendo cocaína, idênticos aos anteriormente encontrados, além de cinquenta porções de maconha. Não conhecia o réu. O bairro é conhecido como ponto de venda de drogas.

O policial militar Luiz Alberto da Costa Araújo, ouvido em juízo (fl. 119), em consonância com o depoimento prestado na fase inquisitiva (fl. 03), relatou que realizavam patrulhamento de rotina, certo que, quando o réu avistou a viatura, dispensou uma sacola plástica. Realizada revista pessoal, foi encontrada com o réu a quantia de R\$ 100,00. Na sacola plástica dispensada havia treze porções de cocaína. Indagado, o réu admitiu que havia mais drogas em sua casa, que distava cerca de 80 metros do local da abordagem. Na residência, o réu informou que havia drogas na gaveta do guarda-roupas, logrando os agentes encontrarem mais cinquenta e uma porções de cocaína, idênticas às anteriormente encontradas na sacola plástica,

além de cinquenta porções de maconha. Na casa não havia mais ninguém. O réu acompanhou a busca realizada no imóvel.

Em seu interrogatório (fl. 120), o réu disse que estava com seu amigo Mateus e por volta de 19h decidiram ir até a rua três para buscar lanche. A comerciante disse que não tinha troco para R\$ 100,00, porque havia acabado de iniciar a atividade. Deste modo, enquanto o lanche era preparado, foram até um bar para tentar trocar o dinheiro. Antes de chegarem lá, porém, foram abordados pelos policiais. Foram detidos por dois policiais, enquanto outros dois foram até um pasto existente na rua quatro, que dista duas ruas de onde estavam. De lá os agentes que depuseram retornaram com uma sacola, onde havia pinos de cocaína. Não jogou nenhuma sacola. Depois disso, os policiais liberaram Mateus. Indagaram se havia drogas na casa do interrogado, respondendo negativamente. Mesmo assim os agentes se dirigiram para lá, mas não pôde acompanhar a busca, porque ficou o tempo todo dentro da viatura. Não havia mais ninguém em sua casa. Não havia drogas. Não fuma maconha. Os dois policiais que depuseram foram até o pasto e voltaram com a sacola. Parentes seus e de Mateus presenciaram toda a abordagem.

Eis a prova oral produzida.

Pela análise do conjunto probatório verifica-se que as drogas apreendidas pertenciam, de fato, ao réu e se destinavam ao tráfico, sobretudo pelo que foi declarado pelos policiais militares ouvidos nos autos, bem como pelas circunstâncias fáticas em que o entorpecente foi encontrado.

Em que pese o réu negar a prática do delito tanto na fase inquisitiva (fl. 09) quanto em juízo, sua versão exculpatória se encontra isolada e em dissonância com as demais provas produzidas.

Neste sentido, embora o acusado tenha dito que os policiais, na verdade encontraram a droga num pasto e que toda a cena foi presenciada por parentes e também por seu amigo, de nome Mateus, não logrou arrolar nenhuma destas pessoas como testemunha.

Em sentido contrário, os policiais militares foram firmes e coerentes ao narrar, com riqueza de detalhes, como se deu a dinâmica dos fatos. Foram uníssonos ao confirmarem em juízo que avistaram o réu, o qual demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura e dispensou uma sacola plástica, dentro da qual foram encontrados pinos contendo cocaína. Na sequência, o próprio réu admitiu aos agentes que em sua casa, mais precisamente numa gaveta do guarda-roupas, havia mais drogas, autorizando e acompanhando as buscas. No local indicado pelo réu foram encontrados mais pinos de cocaína, idênticos àqueles que estavam no interior da sacola dispensada momentos antes, além de porções de maconha.

Verifica-se que os policiais militares prestaram depoimentos extremamente coerentes, claros e concisos tanto na seara policial, quanto em juízo, narrando os fatos com precisão e riqueza de detalhes. Com efeito, não há motivos para se desmerecer as palavras dos agentes, vez que confirmadas pelo auto de exibição e apreensão de fl. 09 e pelos laudos periciais acostados às fls. 27/28 e 61/66.

No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os policiais teriam mentido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Como é cediço, o testemunho policial é de grande valia na prova do tráfico, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-lo, no sentido de querer indevidamente prejudicar o réu, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito.

Com efeito, “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato

de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello).

Nesse sentido, não merece prosperar a tese defensiva de que a inicial acusatória se baseia apenas nos depoimentos apresentados pelos policiais. Registre-se que os relatos prestados pelos agentes públicos são coincidentes entre si, o que lhes confere maior densidade probatória, não havendo nenhuma contradição que se presta a abalar, minimamente, a credibilidade das testemunhas.

De resto, a quantidade de droga apreendida demonstra que efetivamente se destinava ao tráfico, porquanto foram apreendidos treze pinos contendo cocaína e posteriormente mais cinquenta e um, totalizando 49,67 gramas, além de cinquenta porções de maconha, com peso total de 135,84 gramas.

Além disso, as circunstâncias fáticas em que as drogas foram encontradas (em porções individuais), também configuram a prática do delito.

Portanto, não há que se falar em absolvição por falta de provas, como arguido pela defesa, eis que os fatos imputados ao réu ficaram devidamente comprovados pelas provas produzidas pela acusação.

E, ao contrário do que arguido pela combativa defesa, não é necessária a exigência da prova presencial da mercancia do entorpecente para consumir o crime. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova, como de fato se deu no presente caso.

Cabe ponderar, ainda, que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse ou guarda do tóxico pelo agente para entrega a terceiro sendo, portanto, desnecessário que seja ele flagrado vendendo a droga. A propósito, sobre o tema este Tribunal já decidiu que: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP63/316, 70/371 e 97/512).

Quanto à quantia de R\$ 100,00 apreendida nos autos (fl. 60), verifica-se que o réu não demonstrou a origem lícita do dinheiro, certo que tal fato, somado às demais provas dos autos, demonstra a relação do numerário com o comércio nefasto da droga.

Por outro lado, é o caso de acolher o pedido da defesa para que seja aplicada a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, vez que consta nos autos (fls. 29/32) que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Além disso, não ficou comprovado pela acusação que o acusado se dedicava a atividades criminosas e integraria organização criminosa, certo que o ônus da prova acerca da ausência de todos os requisitos previstos no aludido dispositivo legal, que são cumulativos, incumbe à acusação, em decorrência do princípio da presunção de inocência.

Assim, a conduta do réu, consistente nas ações de "trazer consigo" e "ter em depósito" o entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, encontra-se inserida no rol descrito no “caput” do art. 33 da Lei nº 11.343/06, estando demonstrada e caracterizada a prática do crime descrito na peça inicial.

Passo à fixação da pena.

No que toca às circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59, do Código Penal, tenho que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes na esfera criminal (fls. 29/32), nada havendo que justifique a fixação da pena acima do mínimo legal, motivo pelo qual fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa.

Incide no caso a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), uma vez que o réu era menor de vinte e um anos na data dos fatos (fl. 10). Contudo, a pena-base já se encontra fixada no patamar mínimo legal, devendo permanecer inalterada em 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa.

Deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, vez que o réu é primário, de bons antecedentes, e não há provas inequívocas de que se dedique às atividades criminosas e esteja envolvido com o crime organizado. A fração de diminuição deve considerar as circunstâncias do caso concreto, o que mostra proporcional a redução pelo máximo previsto, ou seja, 2/3, em face da natureza e quantidade apreendida. Diminuo, portanto, a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixada no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo, vez que ausentes nos autos elementos que permitam aferir sua capacidade financeira.

Inexistem outras causas de aumento ou de diminuição de pena a se aplicar.

E em recente posicionamento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus Coletivo nº 596.603/SP, foi determinada afixação do regime aberto quando aplicado o redutor previsto no § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), como se deu no caso em comento.

Nesse sentido, em observância à determinação das Cortes Superiores, o réu iniciará o cumprimento de sua pena no regime aberto.

Por conseguinte, tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, por preencher os requisitos do artigo 44, incisos I a III, e § 2º, do Código Penal. A prestação pecuniária consistirá no pagamento, em dinheiro, do valor correspondente a 01 (um) salário mínimo, vigente na data do efetivo pagamento, que será revertido em benefício de entidade pública ou privada com destinação social, conforme artigo 45, § 1º, do Código Penal, observando-se o disposto no § 2º do mesmo artigo. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 46 e parágrafos do Código Penal) terá seu cumprimento disciplinado pelo juízo da execução, conforme as aptidões do réu, e deverá se dar pelo período de 1 (um) ano e 8 (oito) meses.

Incabível no caso a concessão da suspensão condicional da pena (sursis), uma vez que foi deferida a substituição por pena restritiva de direitos (art. 77, inciso III, do Código Penal).

DECIDO.

Ante o acima exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Ministério Público e o faço para CONDENAR o réu KAIIO AUGUSTO DA SILVA SOUSA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, “caput”, cumulado com o § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano

e 08 (oito) meses de reclusão e multa no valor de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com regime aberto para o início do cumprimento. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos moldes expostos na fundamentação desta sentença.

Defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade por estarem mantidas as circunstâncias que o levaram a responder, solto, ao processo até esta fase, não se tendo notícias nos autos de qualquer alteração da situação fática.

DECLARO o perdimento da quantia de R\$ 100,00 (fl. 60) em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, vez que inerente ao crime de tráfico praticado pela sentenciada, expedindo-se o necessário após o trânsito em julgado.

Custas conforme a lei (art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003).

P.R.I.C.

Araçatuba, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA